

1502670-63.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... há vedação expressa para a figura do tráfico de drogas privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Duas posições devem se formar aqui. Primeira no sentido da vedação perante a alegação do caráter hediondo e da gravidade do delito. Discordamos dessa posição desde que se fixou de maneira clara que o tráfico de drogas não é crime hediondo na jurisprudência do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502670-63.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502670-63.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PABLO HENRIQUE TENORIO LIMA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 09 de Março de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, a Defensora Pública, Dra. Fernanda Tartari Frazao de Vasconcelos e o acusado: PABLO HENRIQUE TENORIO LIMA, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/porta1/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa do acusado para apresentação da defesa preliminar. Pelo Defensor Público,

foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito: Vistos. Não obstante os respeitáveis argumentos da ilustre defesa, verifica-se que a prova da materialidade do crime está presente no laudo a que foram submetidas as substâncias apreendidas, bem como os indícios de autoria nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. O mérito depende de apuração processual, não sendo possível neste momento qualquer outra medida diversa do recebimento da denúncia a qual é recebida nesta data. O acusado é citado por vídeo conferência e diante da sua presença nesta data, por economia processual, já fica intimado para audiência que ocorrerá na sequência. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas; Roziel da Cunha Almeida e Enrique de Souza. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, o réu acha-se processados sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida; resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A denúncia é procedente. laudo químico toxicológico consta a fls.155/157. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. Narram os GCMs que o réu, ao vir os GCM, tentou fugir, sendo que o réu dispensou a sua bolsa, mas acabou sendo abordado. Efetuada a revista e apreendida a bolsa adrede dispensada, o réu admitiu que a droga encontrada era dele. O réu admitiu a prática de venda de drogas. O réu foi interrogado e confessou os fatos. Quanto ao depoimento de policiais, [e por extensão os GCM] a jurisprudência dominante é firme no sentido de conferir-lhe validade como qualquer outro, já que como servidores públicos que são, têm no desempenho de suas funções, presunção de agirem escorreitamente no regular cumprimento de suas atribuições, salvo prova em contrário. Oportuno trazer à colação os seguintes julgados: ENTORPECENTES – "Tráfico - Fragilidade probatória - Inocorrência- Depoimentos de policiais sem discrepâncias e em harmonia com a prova - Recurso não provido." (Apelação Criminal n. 227.393-3 - São José do Rio Preto - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 28.08.97 - V.U. * 742/262/05) PROVA CRIMINAL – "Testemunhal - Hipótese de tóxicos - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício da função - Condenação mantida - Recurso não provido." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 154.163-3 - São Paulo - 26.09.94)"Não existe dispositivo legal que vede ao policial ser testemunha e pequenas divergências em depoimentos não anulam a prova, confirmada de forma segura na parte principal." (TACRIM-SP -AC 204.909 - Rel.Castro Duarte -JUTACRIM 60/171)"Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, o policial não está impedido de depor e seu depoimento deve ser valorado como qualquer outro, não se compreendendo que, aprioristicamente, seja repelido como eivado de suspeição ." (TACRIM-SP -AC- Rel. Silva Franco - JUTACRIM 46/365). "Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências." (TJSP -AC- Rel. Silva Leme -RT 417/94). Pelo quadro probatório que restou demonstrado que réu estava com as drogas e que se destinava à venda, ante a forma encontrada, qual seja em porções já prontas e individualizadas, indicando destinação a terceiros, somando-se o depoimento dos policiais quanto a forma do encontro da droga e da

diligência, havendo ainda a confissão. Assim, de rigor a procedência da Denúncia. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tem-se na primeira fase que não há elementos. Na segunda fase observam-se a atenuante da confissão. Na terceira fase constou a comprovação do redutor do parágrafo do artigo 33, pois é primário e não há indicação de organização. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, PABLO HENRIQUE TENORIO LIMA responde por infração, em tese, ao art. 33, 'caput', da Lei 11343/06, cumulado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque supostamente trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 32 invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como Maconha, com peso de 54,7 gramas e 122 invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada "Cocaína" em material sólido particulado, com peso de 65,1 gramas. Em que pesem as ponderações lançadas pelo Ministério Público, a absolvição é medida de rigor, conforme se passa a demonstrar. Inicialmente, impõe-se reconhecer que foram preenchidos todos os requisitos para o oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público relativamente ao acusado. Apesar disso, o Ministério Público afirmou que o acordo de não persecução penal não era cabível, embasando sua negativa tendo em vista que diante da reprovabilidade concreta do delito, não há preenchimento do requisito disposto no artigo 28-A do CPP, qual seja, a medida "não se revelar necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime". A argumentação ministerial, todavia, não se justifica. (fls. 79). De acordo com o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.694/2019, "Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime." Além disso, não caberá o acordo de não persecução penal nos casos em que: a) for cabível a transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais; b) o imputado for reincidente ou houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; c) o imputado tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e d) a persecução penal tiver objeto a apuração de crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor (CPP, art. 28-A, § 2º). Nota-se, com isso, que, no caso ora analisado, estão presentes todos os requisitos para a concessão do acordo de não persecução penal no caso ora analisado: a) o crime imputado ao denunciado foi praticado sem violência ou grave ameaça e seu preceito secundário comina a pena privativa de liberdade inferior mínima a 4 anos, sendo certo que, relativamente ao tráfico de drogas, deve ser levada em consideração a causa de diminuição de pena (CPP, art. 28-A, § 1º); b) o acusado confessou amplamente em juízo. Ademais, deve-se rechaçar a argumentação no sentido de que a imputação do delito tipificado pelo art. 33 da Lei de Drogas impediria a formulação da proposta de acordo de não persecução penal. Isso porque, na hipótese de incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é afastada a hediondez do delito (CPP, art. 28-A, § 1º; LEP, art. 112, § 5º), a demonstrar sua menor reprovabilidade. Nesse sentido, é a lição de Guilherme Madeira Dezem: "Não há vedação expressa para a figura do tráfico de drogas privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Duas posições devem se formar aqui. Primeira no sentido da vedação perante a alegação do caráter hediondo e da gravidade do delito. Discordamos dessa posição desde que se fixou de maneira clara que o tráfico de drogas não é crime hediondo na jurisprudência do STF e do STJ. Dessa forma, em tese, é possível a aplicação do acordo de não persecução penal para os casos envolvendo o tráfico privilegiado e sua recusa deve ser feita de maneira motivada" (DEZEM, Guilherme Madeira. Alterações no Código de Processo Penal (art. 3º), na Lei de Normas Procedimentais perante STF e STJ (art. 16) e no Código de Processo Penal Militar (art. 18). In: DEZEM, Guilherme Madeira; SOUZA,

Luciano Anderson de. Comentários ao Pacote Anticrime: Lei 13.964/2019. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 112). Se é assim, a imputação do delito de tráfico de drogas, caso tenha sido aplicado o redutor previsto pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou caso se vislumbre a possibilidade de sua aplicação, não inviabiliza a proposta de acordo não persecução penal. Não por outro motivo, em situação bastante similar a esta, em recente julgado, o Tribunal de Justiça, ao confirmar a condenação pela prática do delito tipificado pelo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, determinou a remessa dos autos à primeira instância para oferecimento da proposta de acordo não persecução penal: TJ-SP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0002719-85.2017.8.26.0542, Des. Rel. Paulo Rossi, julgado em 11/5/2020. Percebe-se, portanto, que o acordo de não persecução penal é plenamente compatível com o tráfico de drogas em sua forma “privilegiada”. Fixada a premissa de que o tráfico “privilegiado” é compatível com o acordo de não persecução penal, deve-se reconhecer que o novel instituto se configura como um autêntico direito subjetivo do acusado. Nesse diapasão, é preciso rememorar que o princípio da reserva legal instrui o Direito Penal. Ele não só indica que não há crime sem lei, mas traz uma série de consectários. Aqui, vale mais uma vez tratar do primado da *lex stricta*, ou seja, a proibição da analogia em desfavor do cidadão submetido à persecução penal. Quando a lei prevê requisitos para o reconhecimento de um direito, não há espaço para lucubrar se ele pode ou deve ser reconhecido, se há uma faculdade ou um dever. Caso os requisitos estipulados pela lei sejam preenchidos, há o direito. Se ele existe, deverá ser reconhecido. Não há margem para escolha. Isso porque, para negá-lo, nesse caso, o fundamento empregado indubitavelmente restará em algo que a lei não prevê para o caso. O motivo para tanto é simples: a legalidade impede o emprego de analogia em desfavor do investigado. E, para negar o direito nesse caso, é necessário utilizar dado que a lei não previu para tanto. Um exemplo recorrente disso – e que pode ser aplicado ao presente caso por analogia – é o furto privilegiado: se a coisa for de pequeno valor e o réu for primário, a figura existe e será reconhecida. Não há que se falar em maus antecedentes ou valor do prejuízo, “v.g.”, pois não são requisitos legais. Isso acarretaria indevida analogia, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019. Se é assim, tem-se que, diante do preenchimento dos requisitos legais, é impositivo o oferecimento do acordo de não persecução penal. Não por outro motivo, a doutrina sustenta que há um verdadeiro direito subjetivo ao oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal: “A proposta do acordo não representa simples faculdade para o Ministério Público: o seu órgão de execução não pode decidir livremente, por critérios de mera conveniência (pessoal ou política), a respeito da proposta do acordo de não persecução penal, sob pena de violação do princípio da igualdade de tratamento (isonomia). A atuação do Ministério Público seria pautada pela discricionariedade regrada (oportunidade regrada): presentes os requisitos legais estabelecidos no art. 28-A, caput e § 2º, do CPP, o órgão de execução do Ministério Público deve propor o acordo de não persecução penal para o investigado, com as condições (alternativas ou cumulativas) dos incisos I a V do caput. Assim, deve-se compreender o verbo “poderá” (art. 28-A, caput, do CPP) como um “poder-dever”, porquanto vinculado (regulado ou regrado) aos requisitos legais estabelecidos no art. 28-A, caput e § 2º, do CPP” (FULLER, Paulo Henrique. Alterações ao Código de Processo Penal. In: JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz; VANZOLINI, Patricia; FULLER, Paulo Henrique; PARDAL, Rodrigo. Lei Anticrime comentada: artigo por artigo. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 168-169, grifos nossos). Estabelecida essa premissa, conclui-se que, diante da presença dos requisitos legais, o imputado tem direito ao acordo. O Ministério Público, por via de consequência, deveria ter formulado a proposta de acordo de não persecução penal à imputada. De acordo com o art. 28-A, § 14º, do Código de Processo Penal, diante da recusa do Promotor de Justiça em ofertar o acordo de não persecução penal, os autos devem ser encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça. 1. Da ilicitude da abordagem por guardas civis metropolitanos. Todo o conjunto probatório produzido nos autos é inadmissível, nos

termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, eis que a apreensão das drogas pelos guardas municipais se deu em violação a norma constitucional. De fato, os guardas municipais agiram em afronta às suas atribuições constitucionalmente previstas no artigo 144, §8º, da Carta Magna, norma que dispõe que compete à guarda municipal a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não fazendo referência a policiamento ostensivo. Não se olvida que guardas municipais, como qualquer do povo, podem realizar prisões, desde que diante de situação de flagrante delito, o que não ocorreu no caso vertente. Não há que se falar em flagrante, eis que não houve ciência de crime e posterior abordagem. Desse modo, tendo a apreensão das drogas se dado mediante violação a regra constitucional, trata-se de prova inadmissível, que deve ser desentranhada dos autos, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal, sendo o restante do conjunto probatório ilícito por derivação. Por consequência, de rigor a absolvição do acusado, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. No ponto, confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos defensivo e ministerial. Nulidade reconhecida de ofício. Atuação irregular dos guardas municipais. Abordagem do acusado em razão de informações anônimas e ingresso dos agentes públicos na residência do réu após sua confissão informal no sentido de que havia drogas no local. Ausência de mandado judicial. Atuação dos guardas municipais nas funções típicas de Polícia Judiciária e de policiamento ostensivo. Função não prevista na Constituição Federal ou no Estatuto Geral das Guardas Municipais. Prova ilícita, que deve ser desentranhada dos autos. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Absolvição. Recurso defensivo provido. Prejudicada a análise do recurso ministerial. (TJSP; Apelação Criminal 1503628-64.2019.8.26.0548; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022) 2. Do crime de tráfico. No caso deste processo, os depoimentos dos agentes não são suficientes a demonstrar a prática da conduta pela acusada. Com efeito, da acurada análise do conjunto fático-probatório, produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5, LIV e LV, c/c CPP, art. 155), verifica-se que a autoria delitiva não restou adequadamente prova pelos elementos coligidos na fase judicial. Tudo porque: O guarda civil metropolitano Roziel da Cunha Almeida disse que é guarda civil ambiental. O acusado estava em uma área de perímetro ambiental. O acusado e outro amigo saíram correndo ao avistar o depoente. Na revista foi encontrado o dinheiro, 80 reais. Ao ser abordado ele admitiu a traficância. Ele teria dispensado a sacola com drogas na fuga. Havia pessoas no local, praticando caminhada, que não foram identificadas e conduzidas ao distrito policial para testemunhar a abordagem, que se deu por volta das 10h/10h30. O acusado não se disse usuário. Seu colega Enrique de Souza, por seu turno, confirmou suas palavras. Ele foi abordado uns cinco minutos depois. As pessoas se recusam a ser testemunhas da abordagem. Havia 80 reais no bolso. Foram apreendidas cocaína e maconha. Em Juízo, os policiais descreveram apenas as circunstâncias da prisão, buscando legitimar a prisão efetuada. Destarte da acurada análise do conjunto probatório não parece ser possível extrair, com a certeza jurídica necessária, que realmente o réu tinha entorpecentes na sua posse para comercialização. No mais, frise-se que o réu foi abordado na rua, contudo, não há nenhuma testemunha arrolada que viu o réu comercializando drogas, e não foi apreendido celular com mensagens que indicassem a mercancia de entorpecentes – o que é extremamente comum de haver em celular de pessoas que se voltam para o tráfico de drogas. Ou seja, temos um processo em que não há qualquer elemento que indique que o réu praticava o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Como se sabe, o Direito Penal exige a convicção plena do julgador, ancorada em dados objetivos, concretos, irrefutáveis. A dúvida, menor que seja, milita em favor da acusada, como determina o secular princípio do in dubio pro reo (CF, art. 5, LVII). Diante deste contexto, data vênia, surge a dúvida que o favorece. O i. Ministério Público estadual não se desincumbiu do ônus da prova que é exclusivamente seu (CP, art. 156). Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foram

produzidos quaisquer elementos que confirmem a imputação e isso prejudica sobremodo a certeza que deve inspirar o julgador para reconhecer validamente a culpa do acusado. A dúvida sobre a existência e autoria do crime é séria e, por isso, a única solução que se pode dar ao presente caso é aquela que prestigia o princípio in dubio pro reo. Neste sentido, não é possível ter a certeza jurídica necessária para atribuir a responsabilidade penal ao assistido pela infração penal deduzida na denúncia. Diante do exposto, requer a Defesa a ABSOLVIÇÃO do réu, nos termos do art. 386, incisos III, V ou VII, do CPP. 3- Das Teses

Subsidiárias: Caso não seja acolhida a tese absolutória, SUBSIDIARIAMENTE, em atendimento aos princípios da eventualidade e da ampla defesa, requer-se: 3.1. seja fixada a pena base no mínimo legal, ante a ausência de requisitos subjetivos capazes de elevá-la. Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59 do CP e da Sumula 444/STJ, tendo em vista que o acusado era absolutamente primário e com bons antecedentes, pois não ostenta nenhuma condenação com trânsito em julgado contra si. 3.2. seja aplicada a causa especial de diminuição de pena (art. 33, §4º): Isso porque de acordo com o mencionado dispositivo legal: “Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Não há nada nos autos a evidenciar que o réu, que é primário e não possui antecedentes criminais, possua ligação com atividades ou organizações criminosas, sendo certo que qualquer conclusão neste sentido não passa de mera presunção. De outra parte, nada há na lei de drogas a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena simplesmente em razão da natureza ou variedade da substância entorpecente apreendida. Ressalte-se, ainda, que não se pode afastar o exercício de direitos pela acusada com base em especulações, sendo certo que a Constituição da República veda expressamente que sejam feitas presunções desfavoráveis à acusada (CF, art. 5, LVII). Nem se diga que a quantidade de droga é impeditiva à aplicação da benesse. Nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive para apreensão de 317,7kg de entorpecentes, quantidade muito superior àquela observada no caso em tela: “Nota-se, portanto, à toda evidência, que a sentença condenatória não se compatibiliza com a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). (...) Ademais, observo que a condição de mula não é apta a sustentar, isoladamente, a não aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois a atuação do agente no transporte do entorpecente não leva à automática conclusão de que se dedica à prática delitativa ou integra organização criminosa (...). Com efeito, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição de pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante. Todavia, diante do limite cognitivo desta Suprema Corte, o ajuste na dosimetria deve ser implementado pelas instâncias ordinárias. Caberá, portanto, ao Juízo de origem refazê-la, aplicando o redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.” (HC 192.619/SP, Relator: Min. Edson Fachin, DJe 19.10.2020) (grifos inseridos). Assim, presentes os requisitos legais, visto que o réu é tecnicamente primário, não há como se negar a aplicação do redutor em seu patamar máximo, ou seja, 2/3. Ademais, o fato de haver processo em andamento não obsta a aplicação da minorante, conforme assente entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade,

na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – CONDENAÇÕES NÃO DEFINITIVAS. Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior. (o destaque não é original). (HC 166385, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020).

3.3. Não procede o reconhecimento da agravante atinente ao estado de calamidade pública, pois nada indica que a pandemia facilitou de qualquer modo a prática do crime. Não consta dificuldade de patrulhamento por parte do estado, e em junho teve início a flexibilização das restrições até então impostas. No ponto, confira-se o entendimento esposado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo: Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas. Pleiteia, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, a aplicação do benefício do privilégio e a conversão em pena restritiva de direitos. Materialidade e autoria comprovadas. Pena base devidamente exasperada. Agravante da calamidade pública afastada. Inviabilidade da aplicação do privilégio e da conversão. Recurso parcialmente provido. (grifei). (TJSP; Apelação Criminal 1510027-65.2020.8.26.0228; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020).

FURTO QUALIFICADO – Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação e também em relação às qualificadoras reconhecidas – Pena-base bem exasperada em 1/3 diante do número de qualificadoras e também da insistência do réu em praticar crimes e do fato de ter sido praticado em um lar – Possibilidade de, no específico caso dos autos, afastar a agravante consistente na calamidade pública, por não parecer circunstância que facilitou o crime – Repouso noturno bem reconhecido, afastada a incompatibilidade com as qualificadoras – Possibilidade de alteração do regime prisional para o intermediário – Recurso parcialmente provido (voto nº 43394). (destaquei).

(TJSP; Apelação Criminal 1510014-66.2020.8.26.0228; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data de Registro:

16/11/2020) Furto qualificado – Pena base – Condenações antigas – Maus antecedentes – Configuração – Precedentes – Prejuízo causado pelo arrombamento – Invasão de estabelecimento comercial – Circunstâncias inerentes ao tipo, que não servem para justificar maior exasperação da pena base; Furto – Calamidade pública – pandemia de COVID-19 – Circunstância que não contribuiu para a realização do tipo – Agravante – Não configuração; Prisão em flagrante – Atenuante da confissão – Reconhecimento – Inteligência da Súmula nº 545, do c. STJ; Furto noturno – Estabelecimento comercial – Majorante – Incidência – Réu multirreincidente específico – Regime fechado – Cabimento – Detração – Matéria afeta ao juízo da Execução criminal – Recurso provido em parte para a redução da

pena. (destaquei) (TJSP; Apelação Criminal 1507342-85.2020.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020) Caso este não seja o entendimento de Vossa

Excelência requer ao menos a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. 3.4. o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da

minoridade relativa. 3.5. Detração e fixação do regime inicial menos gravoso

(aberto ou, eventualmente, o semiaberto): para o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade, considerando o quantum da reprimenda (CP, art. 33), e a ausência de circunstâncias pessoais e objetivas desfavoráveis, em especial a primariedade do réu (Súmulas 440/STJ; 718 e 719/STF). De rigor, ainda, a aplicação do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. 3.6. Substituição da

pena privativa de liberdade por

restritivas de direitos: No caso concreto, deve ser deferida a substituição de prisão por restritiva de direitos, adotando-se o novo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (HC 97.256) que entende eu inconstitucional a vedação

abstrata da substituição da pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de drogas. Assim, verifica-se que as circunstâncias favoráveis ao assistido justificam a resposta penal mais branda. É por esta lógica que a lei não pode conferir tratamento igual a fatos que necessariamente terão características e circunstâncias distintas. Dessa forma, a resposta penal não pode ser piorada simplesmente porque o crime em questão é tráfico de drogas. É justamente este tratamento igual a fatos distintos que a Lei de Crimes Hediondos não pode impor. Cabe aos juristas interpretar tal lei de forma a encontrar o verdadeiro sentido constitucional daquelas normas. Neste sentido, para que a punição seja legítima e esteja em conformidade com o Estado Democrático de Direito (CF, art. 1), há que se considerar para tanto as circunstâncias concretas em que o crime foi praticado, assim como a quantidade de pena e os possíveis antecedentes da acusada. Ante o exposto, a substituição da reprimenda corporal pela alternativa é direito subjetivo do acusado, eis que preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44 e 59); 3.7. A concessão do direito de recorrer em liberdade (CADH, art. 8.1 e CPP, art. 312): eis que ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar (CF, art. 5, LVII, c/c CPP, art. 312). A inexistência de notícia de fato concreto, passível de caracterização dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, desautoriza a manutenção da custódia cautelar do acusado (STJ, HC 96.980/PA). De acordo com a lição de EUGENIO PACELLI OLIVEIRA, "[...] (probabilidade de fuga) e outra (a probabilidade de condenação) não são suficientes para, por si só, justificarem a prisão, dado que nenhuma delas atende a exigência constitucional, expressa na seguinte norma: ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (art. 5, LXI)". Por isso, a Defesa Pública entende que a revogação da cautelar é a medida jurídica mais adequada ao caso. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos Etc. PABLO HENRIQUE TENORIO LIMA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 10:00 horas, durante reconhecido estado de calamidade pública (em plena vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 e do Decreto Legislativo Federal nº 06/2020, com vigência prorrogada pela decisão do STF na ADI n. 6625, (decretos de calamidade pública), na Rua Raimundo de Noronha, altura do número 1, bairro do Jardim Helena, nesta cidade de São Paulo, o acusado, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade de 32 invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada vulgarmente como "Maconha", presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, com peso líquido de 54,7 gramas e 122 invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada vulgarmente como "Cocaína" em material sólido particulado, com peso de 65,1 gramas, além de R\$80,00, em dinheiro, relacionados com o crime em questão, momento em que foi preso por guardas civis metropolitanos que passavam pelo local e desconfiaram das atitudes do acusado e de outro rapaz que estava com ele e conseguiu fugir. Os policiais visualizaram o acusado e o seu cúmplice, em ponto conhecido como de venda de drogas, momento em que houve a tentativa de fuga, não sem antes do réu se desfazer das drogas que estavam no interior de uma bolsa. O dinheiro e as drogas foram apreendidos com o acusado, o qual confessou a traficância ilícita na fase policial. A prisão preventiva foi decretada. O réu foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi realizada. A defesa preliminar não teve o condão de impedir o recebimento da denúncia que ocorreu no dia 09 de março de 2022. Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e interrogado o réu. O laudo definitivo foi apresentado nos autos (fls. 155/157). Ao final, em sede de debates, a acusação, em resumo, pediu a condenação, enquanto a defesa, em resumo, pediu a absolvição. Apresentado o relatório, Decido. I. Não há nulidades e houve amplo contraditório. A cadeia de custódia das drogas foi preservada, considerando as peculiaridades do caso e a própria natureza do crime. O fundado motivo para a legitimação da busca e apreensão pessoal ficou demonstrado no fato de que o réu estava com uma sacola na mão, tentou disfarçar diante da presença policial, em um ponto conhecido como de venda de drogas. O acusado estava em situação de flagrante delito, uma vez que na posse das drogas com

o intuito de venda, o que caracteriza crime permanente e autoriza qualquer um do povo realizar a prisão e com muito mais razão os guardas civis metropolitanos que acabam sendo um braço de auxílio policial a serviço do cidadão, mormente em zonas periféricas. II. O acusado não demonstra indícios de comprometimento das suas faculdades mentais para ensejar a necessidade de incidente de dependência toxicológica. III. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque o Ministério Público não fez a proposta e a quantidade de drogas não é invulgar para o tráfico de drogas na modalidade do varejo. IV. O réu não demonstra indícios de comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica. V. A questão envolvendo o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, bem como de eventuais vítimas das infrações penais não podem dar margem a uma premissa equivocada de parcialidade e de interesse em prejudicar quem quer que seja. Os policiais, bem como as vítimas pessoas físicas, como também os acusados, até prova em contrário, merecem o respeito por parte do Juízo. Inclusive, o conteúdo dos seus depoimentos e declarações, não são mais ou menos válidos e precisam ser analisados em conjunto com os demais elementos de convicção existente nos autos. A defesa de postura diversa, respeitosamente, representa mero preconceito que precisa ser afastado em um processo judicial. Neste sentido, encontram-se os julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com destaque para o HC 165.561/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, da 6ª Turma, publicado no DJe no dia 15/02/2016; HC 30.776/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, da 5ª Turma, publicado no DJe no dia 8/3/2004. Logo, a mera condição de policial ou de vítima não se prestam para afastar a credibilidade do conteúdo das informações trazidas para os autos, representando meio de prova eficaz e válido, ainda que isolado de outros elementos de convicção, desde que dentro de um contexto e de uma coerência, mormente quando avaliado diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram e pela ausência de explicações e justificações adequadas por parte da defesa. VI. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos, oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram "Cocaína" (BENZOILMETTILECGONINA), e "Maconha" (cannabis sativa L), presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, conforme laudo pericial de fls. 13/16, 155/157. Demonstrado que as substâncias apreendidas eram "Cocaína" e "Maconha", a materialidade do crime está provada. VII. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, as circunstâncias que envolveram a apreensão dos entorpecentes, a quantidade, a natureza diversificada e o modo como estavam embalados separadamente, sem me olvidar das declarações do acusado e das manifestações das partes, a condenação é de rigor e pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 10:00 horas, durante reconhecido estado de calamidade pública (em plena vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 e do Decreto Legislativo Federal nº 06/2020, com vigência prorrogada pela decisão do STF na ADI n. 6625, (decretos de calamidade pública), na Rua Raimundo de Noronha, altura do número 1, bairro do Jardim Helena, nesta cidade de São Paulo, o acusado, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade de 32 invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada vulgarmente como "Maconha", presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, com peso líquido de 54,7 gramas e 122 invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada vulgarmente como "Cocaína" em material sólido particulado, com peso de 65,1 gramas, além de R\$80,00, em dinheiro, relacionados com o crime em questão, momento em que foi preso por guardas civis metropolitanos que passavam pelo local e desconfiaram das atitudes do acusado e de outro rapaz que estava com ele e conseguiu fugir. Os policiais visualizaram o acusado e o seu cúmplice, em ponto conhecido como de venda de drogas, momento em que houve a tentativa de fuga, não sem antes do réu se desfazer das drogas que estavam no interior de uma bolsa. O dinheiro e as drogas foram apreendidos com o acusado, o qual confessou a

traficância ilícita na fase policial. Posteriormente, ao ser interrogado, o acusado confessou o crime em questão. Tal confissão foi corroborada pelos policiais ouvidos, os quais

foram uníssonos e seguros com relação à posse dos entorpecentes por parte do acusado, bem como apresentaram o justo motivo para a busca e apreensão pessoal. Inclusive, deixaram claro que o local é ponto conhecido de venda de drogas e que eles estavam no apoio de outros policiais que investigavam o tráfico ilícito de entorpecentes no local. Portanto, não existem dúvidas da autoria e da materialidade do crime em questão. O réu estava vendendo drogas e, possivelmente, utilizava-se do disfarce de trabalhar no lava-rápido para desenvolver a sua atividade sem levantar suspeitas. O dinheiro apreendido está relacionado com a traficância, haja vista a proximidade com as drogas, motivo pelo qual determino a sua perda. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. Importante consignar que a conduta do acusado é um relevante legal, prevista como crime e fomentadora da miséria social, motivos pelos quais não pode ser dita como algo insignificante para a vida em sociedade. VIII. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 42 e 43 da Lei de Tóxicos, as quais não são diversas de casos análogos, as penas básicas são fixadas no patamar mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Na segunda fase, embora o réu seja confesso, as penas básicas já foram fixadas no patamar mínimo legal, motivo pelo qual não cabe redução em face da natureza jurídica do instituto da atenuante. A questão da agravante da calamidade pública impõe algumas considerações. Inicialmente, necessário um decreto que reconheça a situação de calamidade pública, sendo que no Estado de São Paulo isso ocorreu com o Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, criado em face do advento da pandemia do COVID-19. Também, conforme entendimento majoritário da jurisprudência dos Egrégios Tribunais Pátrios se faz necessária a demonstração de que o estado de calamidade pública tenha de qualquer forma concorrido para o crime em questão. Portanto, o que se observa é que o critério não é apenas objetivo, devendo ser demonstrado que a situação de calamidade pública, de alguma forma, tenha permitido o crime praticado. Logo, verificamos que a nossa posição anterior de ser um critério objetivo não se sustenta no atual quadro jurisprudencial dos Egrégios Tribunais Pátrios, sendo as reformas das decisões em sentido contrário uma constante. Em face do exposto, atento ao posicionamento jurisprudencial, o qual é um modelador dos julgamentos dos magistrados de primeiro grau de jurisdição, revejo o meu posicionamento anterior para afastar a agravante da calamidade pública porque não restou demonstrado que tal situação tenha concorrido ou mesmo facilitado a prática do crime sob análise. No sentido do que foi acima exposto, destacam-se os julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça junto ao HC 625.645/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 04/12/2020; bem como o julgado no HC 632.019/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 10/2/2021; o julgado no HC 629/981/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado no DJe 9/2/2021 e, finalmente, o que foi julgado junto ao HC 620.531/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no DJe 3/2/2021. Já na terceira fase da aplicação da pena, por conta do redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, uma vez que o réu é primário e não há provas de que faça parte de organização criminosa, as penas são reduzidas em 2/3, passando para 1 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias multa, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do acusado. Considerando as peculiaridades do caso, a posição jurisprudencial padronizada dos E. Tribunais Superiores, o réu poderá recorrer em liberdade e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Não se aplica o disposto no artigo 387 parágrafo segundo do CPP, em face do regime prisional inicial ser o aberto. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar PABLO HENRIQUE TENORIO LIMA, RG/SP nº 53928278, nascido em 11/08/2003, filho de Evilasio Tenório Silva e de Isadora Lima Rodrigues Leal, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, com início no regime aberto, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e

166 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", §4º da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Condene o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da Justiça Gratuita. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Oficie-se para a destruição dos entorpecentes apreendidos e guardados para novos exames, uma vez que já há laudo definitivo não impugnado. Conforme posição pacificada dos E. Tribunais Superiores, aplica-se ao caso o disposto no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços para a comunidade pelo mesmo prazo e em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções Penais. Também, por 10 dias multa, no valor mínimo unitário legal, a se somar à pena pecuniária. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados. Os valores apreendidos estão relacionados com o tráfico de drogas, uma vez que apreendidos junto com as drogas e em local de traficância conhecida, motivos pelos quais determino a perda e o encaminhamento para o fundo nacional criado com essa finalidade. Determino a perda e a destruição dos demais bens apreendidos e não devolvidos, em face da relação com o crime praticado. Oficie-se para tanto. Publicada a sentença em audiência pelas partes e pelo réu foi dito que não tinham interesse em recorrer. Nada mais. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital